

刑法
No15

共通問題 R2-1

(配点：2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、Xに対し、暴行や脅迫を用いて、自殺するように執拗に要求し、要求に応じて崖から海に飛び込んで自殺するしかないとの精神状態に陥らせた上で、Xを崖から海に飛び込ませて死亡させた。この場合、甲に、Xに対する殺人罪は成立しない。
2. 甲は、迫死する意思がないのにあるように装い、その旨誤信したXに心中を決意させた上で、毒物を渡し、それを飲み込ませて死亡させた。この場合、甲に、Xに対する殺人罪は成立しない。
3. 甲は、財物を奪取するために、当該財物の占有者Xに対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫を用いて、当該財物を差し出すしかないとの精神状態に陥らせた上で、当該財物を差し出させた。この場合、甲に、Xに対する強盗罪は成立せず、窃盗罪の間接正犯が成立する。
4. 甲は、日頃から暴行を加えて自己の意のままに従わせて万引きをさせていた満12歳の実子Xに対し、これまでと同様に万引きを命じて実行させた。この場合、Xが是非善悪の判断能力を有する者であれば、甲に、窃盗罪の間接正犯は成立せず、Xとの間で同罪の共同正犯が成立する。
5. 甲は、Xが管理する工事現場に保管されている同人所有の機械を、同人に成り済まして、甲をXであると誤信した中古機械買取業者Yに売却し、同人に同機械を同所から搬出させた。この場合、甲に、Xに対する窃盗罪の間接正犯が成立する。

No15	間接正犯	正答率
共通R2-1	正解	93%

1 誤っている

最決平 16.1.20 (百選 I 73 事件)。本記述では、被害者自身の行為を利用した場合、利用者が殺人罪の正犯となるかが問題となる。利用者の指示通り被害者が海中に飛び込んだが、助かったという事案において、判例は、「被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たる」とし、結論として、「殺人未遂罪に当たる」としている。その理由として、判例は、「本件犯行当時、被害者をして、被告人の命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたものといえる。被告人は、以上のような精神状態に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたものである」ということを挙げている。したがって、甲には、X に対する殺人罪が成立する。

2 誤っている

最判昭 33.11.21 (百選 II 1 事件)。本記述では、被害者の錯誤を利用した場合において、利用者に自殺教唆罪が成立するにとどまるか、殺人罪の正犯が成立するかが問題となる。判例は、「通常の殺人罪に該当する」としている。理由として、「被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである」とし、同意が「被害者の自由な真意に基かない場合は刑法 202 条にいう被殺者の囑託承諾としては認め得られない」ということを挙げている。したがって、甲は殺人罪の正犯となる。

3 誤っている

東京高判昭 42.6.20。強盗罪が成立するためには、暴行脅迫により、被害者などの反抗を抑圧して財物を奪取すること（強取）が必要である。反抗を抑圧された被害者から、その意思に反して財物を奪取する場合が強取の典型例であるが、裁判例によれば、反抗を抑圧された被害者が差し出す物を受け取る場合なども強取に含まれる。したがって、甲には、X に対する強盗罪が成立する。

4 誤っている

最決昭 58.9.21 (百選 I 74 事件)。本記述では、被利用者が是非善悪の判断能力を有している場合に、利用者に共同正犯が成立するかが問題となる。判例は、「同女が是非善悪の判断能力を有する者であったとしても……窃盗の間接正犯が成立する」としている。その理由として、判例は、「日頃……暴力を加えて自己の意のままに従わせ……自己の日頃の言動に畏怖し意思を抑圧されている同女を利用して右各窃盗を行ったと認められる」ということを挙げている。したがって、甲には窃盗罪の間接正犯が成立し得る。

5 正しい

最決昭 31.7.3。本記述では、事情を知らない買主を利用した場合に、売主が窃盗罪（235 条）の間接正犯となるかが問題となる。判例は、「売主は「窃盗罪の刑事責任を免れることはできない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、行為者が、構成要件結果について故意のない媒介者の行為を介入させた場合には、媒介者を道具のように利用して構成要件を実現したとみることができる」ということを挙げている。したがって、甲には窃盗罪の間接正犯が成立する。